

1500167-18.2022.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OVANCIR SILVA DELUCA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

OVANCIR SILVA DELUCA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500167-18.2022.8.26.0633 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 17/08/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500167-18.2022.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OVANCIR SILVA DELUCA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

OVANCIR SILVA DELUCA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos delituosos narrados na introital de fls. 01/02, a saber:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de abril de 2022,

por volta das 18h16min, na Rua Emerson da Silva, 1, Oásis, nesta cidade e comarca de Itanhaém, OVANCIR SILVA DELUCA, qualificado à fls. 24, trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, 54 (cinquenta e quatro) pequenas pedras de crack, pesando aproximadamente 0,24 gramas, 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína, pesando aproximadamente 0,48 gramas, 26 (vinte e seis) porções de cannabis sativa L, pesando aproximadamente 0,51 gramas, cf. auto de constatação preliminar de fl. 13, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como o valor de R\$ 79,00 (setenta e nove reais) e dois pedaços de papel com anotações contábeis. Apurou-se que o denunciado trazia consigo os entorpecentes acima descritos, dentro de uma sacola plástica verde e, ao perceber a aproximação de policiais militares tentou evadir, correndo em direção ao matagal, contudo, foi alcançado e preso em flagrante, seguindo-se a apreensão das drogas, de anotações típicas de tráfico e de diversas cédulas e moedas oriundo do comércio ilícito.”.

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram juntados, dentre vários outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls. 10/12), o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), o auto de constatação preliminar de substância entorpecente apreendida (fls. 15/16), a nota de culpa (fl. 22), o comprovante de depósito (fl. 96), o laudo toxicológico (fls. 97/99) e o relatório lavrado pela Polícia Judiciária (fls. 100/101).

Por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública (fls. 56/58). Na sequência, foi acoplado aos autos o mandado de prisão devidamente cumprido (fls. 76/77).

Às fls. 87/88 foi recebida a denúncia, bem como determinou-se a citação do acusado, nos termos do artigo 369-A do Código de Processo Penal. Citado, apresentou resposta à acusação às fls. 109/110, por intermédio de defensora dativa. Por não ser o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 115/117).

Na data aprazada (fls. 133/134), foi inquirida a testemunha Rodrigo. Entretanto, haja vista que a testemunha Admir, arrolada em comum pelas partes, não compareceu ao ato e a defesa insistiu em sua oitiva, foi designada nova audiência (fl. 136).

Na solenidade, abertos os trabalhos, ressaltou-se que o réu seria interrogado após a inquirição das testemunhas arroladas, seguindo a mesma sistemática do procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Na sequência, foi inquirida a testemunha Admir, bem como foi interrogado o acusado. Então, rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. A acusação, em linhas gerais, propugnou pela integral procedência da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do réu, sob a égide da anêmia de provas.

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação do acusado Ovancir Silva Deluca nas sanções do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A materialidade da narcotraficância encontra-se sobejamente evidenciada por intermédio do auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), do auto de constatação prévia de entorpecente (fls. 15/16) e, principalmente, pelo laudo toxicológico de fls. 97/99, oportunidade em que concluíram os experts tratarem-se as substâncias apreendidas de Cocaína (32,4g) e Tetrahidrocannabinol (45,6g). A autoria do acusado, da mesma forma, malgrado o louvável esforço da defesa, ressuma igualmente caracterizada pela prova testemunhal produzida.

Quando de seu interrogatório realizado na fase indiciária (fl. 08), o acusado fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, negou os fatos. Salientou que foi até a "biqueira" unicamente para comprar entorpecente, pois é usuário. Quando da abordagem policial, o traficante correu, deixando o entorpecente, acondicionado em um sacola, entre uma moita e uma árvore. Somente reconheceu o policial Admir como estando presente no dia dos fatos.

Todavia, quando confrontada a versão externada pelo réu com as demais provas produzidas, desfalece ante sua fragilidade, evidenciando, sobremaneira, tratar-se de um subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal.

O policial militar Rodrigo, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 05) e em Juízo (fl. 135), aclarou que na data dos fatos, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Oásis, ao adentrar a Rua Emerson da Silva, conhecido ponto de tráfico de drogas, avistou um indivíduo. Acontece que este, ao notar a presença da viatura, evadiu-se correndo à área de mangue carregando uma sacola plástica verde. Ao alcançar o sujeito, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em suas vestes, porém, na sacola que levava consigo, foram localizados 55 (cinquenta e cinco) pinos contendo cocaína, 54 (cinquenta e quatro) pedrinhas de crack e 26 (vinte e seis) porções de maconha, quantia em cédulas e moedas, somando R\$79,00 (setenta e nove reais) e 02 pedaços de papel contendo anotações contábeis aparentemente relativas ao comércio ilícito.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo policial militar Admir, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 07) e sob o crivo do contraditório, na presente data. Importante destacar que o policial ainda destacou na presente solenidade ter visualizado o réu trazer consigo a sacola em que encontrados os entorpecentes.

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97; pág. 12.189).

Em outras palavras, segundo os milicianos, ao realizarem patrulhamento de rotina, depararam-se com o acusado. Este, ao notar a aproximação dos policiais, esboçou exacerbado nervosismo e saiu em disparada, rumo a um mangue, o que ensejou sua abordagem. Ao efetuarem revista pessoal no acusado, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, na sacola em que carregava, localizaram uma quantidade de drogas e R\$ 79,00 em espécie.

Estas são as provas. Diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, entendo assistir razão à acusação na imputação de tráfico que é ofertada ao acusado. É que a quantidade da droga encontrada (32,4g de Cocaína e 45,6g de Tetrahydrocannabinol) e as circunstâncias que envolveram o caso (a forma como estava acondicionado o entorpecente e apreensão de dinheiro com o réu), transparecem a finalidade comercial própria do tipo penal.

Observe-se ainda que os entorpecentes apreendidos já se encontravam em pequenas porções, adredemente preparados para venda, e que a abordagem fora realizada após a atitude suspeita esboçada pelo acusado. Veja-se que os depoimentos prestados pelos policiais mostraram-se harmônicos sendo, ainda, secundados pela apreensão de entorpecentes.

Todo o contexto da situação flagrancial não deixa dúvidas acerca da conduta ilícita cometida pelo acusado. De resto, não se pode imaginar razões que justifiquem a alegação de estarem os policiais a acusar um desconhecido da prática de um delito, quando isso não ocorreu, unicamente para atender a algum sentimento íntimo sádico de culpar terceiros.

Diga-se de passagem, oportuno lembrar que:

“o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo”(STJ; HC27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006)

E ainda:

“considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.”(STJ; HC34374/MS, Min. Gilson Dip p; Quinta Turma; DJ 01/07/2004)

Em resumo, encontra-se, pois, o acusado incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DA PERDA DOS BENS:

Pela legislação em vigor, são três os tipos de bens que podem ser apreendidos: a) produtos do crime (artigo 60): vantagem direta obtida com a prática criminosa. Ex: o dinheiro recebido com a venda da droga; b) proveito auferido (artigo 60): é a vantagem indireta, conseguida a partir do produto, v.g., um carro comprado com a venda da droga; c) veículos, embarcações, aeronaves, maquinários, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática de crimes previstos na Lei (artigo 62).

Ademais, acentua a doutrina mais judiciosa que para a decretação da perda dos bens e valores apreendidos, mostra-se necessária a demonstração do nexo etiológico a os unir com o crime apurado.

Pois bem, no caso dos autos, tenho de ser o caso de se determinar o perdimento, do valor apreendido de R\$ 79,00 reais (fl. 96), pois o contexto em que fora localizado deixa evidente, portanto, que o lucro foi adquirido proveniente da traficância, tratando-se, portanto, de proveito auferido.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada normal.

Não obstante reincidente (fl. 54), o acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva (fora dos casos de reincidência), tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale

dizer,

“(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado”(STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios à espécie. As circunstâncias e as consequências devem ser consideradas normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Presente a agravante da reincidência (vide certidão de fl. 54 - condenação pelo crime de tráfico, processo nº 0000881-62.2017.8.26.0266, 1ª Vara da Comarca de Itanhaém). A este respeito, anoto que, se uma exasperação da reprimenda é de rigor, estando presente a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, em se tratando de um caso de reincidência específica, a resposta punitiva do Estado deve se fazer sentir com maior severidade, porquanto evidenciados o fracasso das penas anteriormente impostas, sobretudo em sua finalidade preventiva específica, e a recalcitrância do réu em amoldar sua conduta a padrões dignos de conduta. Assim, agravo a pena em 1/5, por se tratar de reincidência específica.

“(...) 1. O Código Penal não especifica limites mínimo e máximo de exasperação ou redução de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas, cabendo ao magistrado, de maneira prudente, com observância ao livre convencimento motivado, fixar o patamar que entender necessário e suficiente à espécie, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se, assim, de discricionariedade vinculada à devida fundamentação. 2. In casu, o acréscimo da pena pela reincidência se deu em 1/4, fração de aumento que não se mostra desarrazoada, tendo em vista escorreita valoração dada diante da reincidência específica do paciente. Não há falar, pois em constrangimento ilegal. (...)”(STJ-HC: 397898 RJ-2017/0097255-9. Relator: Ministra MARIATHEREZA DE ASSIS MOURA. DJ: 23/05/2017, T6. DP: DJe30/05/2017).

Ausentes quaisquer atenuantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição, inclusive a prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em face da reincidência do acusado.

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei n. 11.343/06.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do art. 2º, §1º, da Lei n. 8.072/90, e dada à reincidência operada.

A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito há de ser analisada sob o prisma do art. 44 do Código Penal. Conquanto expressa a vedação acerca da aplicação do instituto aos casos de tráfico, tal qual se depreende dos artigos 33, §4º, e artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06,

o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 97256, publicado em 16/12/2010, cujo relator foi o Min. Ayres Brito, em controle difuso de constitucionalidade, concedeu a segurança pretendida para:

“remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.” E isso por se entender que “o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.”

Ademais, em 15/02/2012, o Senado Federal, valendo-se da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 52, inc. X, da Constituição Federal, editou a Resolução n. 5, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ainda que a Resolução editada pelo Senado Federal tenha se limitado a suspender a restrição existente somente no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, forçosa é a extensão de sua leitura também para a redação dada ao art. 44 do mesmo diploma, quando veda o mesmo benefício. É que o precedente jurisprudencial que motivou a edição da Resolução referida entendeu por inconstitucional tanto a vedação contida no art. §4º do art. 33 como também a do artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06.

Todavia, mesmo que assentadas tais premissas, as circunstâncias do caso indicam não ser recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ainda, a suspensão condicional de sua execução (artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal). Como já positivado, além de a pena aplicada afrontar o requisito legal, o acusado é reincidente.

DIANTE DO EXPOSTO:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado OVANCIR SILVA DELUCA, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, dado o contexto de vulnerabilidade financeira denotada.

Por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante os fundamentos elencados na decisão de fls. 56/58, não reconheço ao acusado o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se o ergástulo em que se encontra até o trânsito em julgado (artigo 387, §1º, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal).

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da

tabela do convênio OAB – Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s). Expeça-se certidão com o trânsito em julgado.

Decreto a perda em favor de entidade beneficente cadastrada neste Juízo do dinheiro apreendido (vide fl. 96, R\$ 79,00 reais).

Transitada em julgado, adote-se as seguintes medidas:

- i) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal;
- ii) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento;
- iii) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença;
- iv) expeça-se a competente certidão de honorários, em valor fixado no máximo constante da tabela do Convênio;
- v) Desde logo, não havendo interesse em recorrer, sai a parte acusada intimada para pagamento da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias. Sem prejuízo, extraia a serventia certidão de sentença a respeito da pena de multa imposta, abrindo-se vista ao Ministério Público;
- vi) Transfira-se para entidade beneficente o dinheiro apreendido (fl. 96, R\$ 79,00 reais).

Registre-se. Cumpra-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA